

1500946-24.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO JOSE DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

FERNANDO JOSÉ DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500946-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500946-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO JOSE DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

FERNANDO JOSÉ DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque 10 de janeiro de 2022, por volta de 09h30, na Rua Olga Fadel Abarca, nº 190, Cidade Lider, nesta cidade e comarca da Capital, portava e trazia consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 262 papérolas de maconha, com peso de 1,4269 kg e 400 pendorfs contendo crack, com peso de 55,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado, notificado nos termos do que dispõe o artigo 55, da Lei nº 11.343/2006, apresentou Defesa Prévia, subscrita por Defensora constituída nos autos (págs. 82/83).

Recebida a denúncia (págs. 133/136), foram ouvidas as testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Alternativamente, requereu: fixação da pena no mínimo legal; acréscimo na fração mínima por força da reincidência; regime de cumprimento diverso do fechado; e, por fim, seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do tráfico de drogas veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04 e seguintes); pelo boletim de ocorrência (págs. 10/12); pelo auto de exibição e apreensão (págs. 16/17); pelo laudo de constatação (págs. 34/36); imagem das drogas apreendidas (pág. 37); pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 102/404), que resultou positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína; e pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado nada declarou, e optou por permanecer em silêncio (pág. 13).

Em juízo, já sob o crivo do contraditório, negou o cometimento do crime.

Declarou que à época estava trabalhando na feira e na manhã que foi preso era seu dia de folga.

Esclareceu que reside naquela rua e um colega - cujo nome não soube informar - o contratou para ajudá-lo a carregar alguns blocos para cima de uma laje.

Esse contato foi intermediado por seu amigo, conhecido por "Bibi".

Disse que estava carregando os blocos. Foi surpreendido pelos policiais no momento em que estava na parte de cima da laje, acabou caindo e machucou os pés.

Justificou que pulou da laje, o que causou sua queda, o que fez atendendo a determinação dos policiais, justificando que ficou com medo frente as ameaças feitas por eles, que afirmaram que iriam efetuar disparos.

Afirmou que não sabia que havia drogas em cima da laje, e os policiais não lhe mostraram entorpecentes.

Questionado pela representante do Ministério Público, disse que já respondeu pelo mesmo crime, ocorrido no mesmo local, mas que não o praticou e sua condenação foi injusta.

Acrescentou, ao final, que não conhecia os policiais civis que o abordaram.

Referida exculpatória, além de previsível e bem pouco consistente, restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutada cabalmente pela prova adversa - notadamente pelo firme relato das testemunhas inquiridas, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante que realizaram -, comprometendo sobremaneira o réu.

Os policiais responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram ouvidos, apresentaram esclarecimentos harmônicos e consistentes, narraram de forma insuspeita como se desenrolou a ação, ensejada por uma denúncia anônima dando conta da prática de comércio ilícito de entorpecentes em local já conhecido como ponto de venda de drogas.

Dirigiram-se ao local indicado na denúncia, verificaram que era uma viela, e

surpreenderam o acusado em cima de uma laje, na posse de uma sacola plástica. Próximo a ele, na calçada, havia outro indivíduo, depois identificado como Richard.

Ao notar a presença policial, o acusado saltou da laje em direção ao solo, oportunidade em que se lesionou, fraturando os pés. Abordaram o réu e a testemunha Richard, e não encontraram qualquer substância ilícita em poder deles.

Foram verificar o local onde estava o acusado e localizaram a sacola que viram em poder dele, e que continha várias porções de maconha e crack. Ressaltaram que não havia mais ninguém em cima dessa laje, apenas o acusado.

Questionado, informalmente, Richard a lhes informou que estava no local para adquirir droga para seu consumo.

Narraram, ainda, que o acusado não ofereceu resistência quando foi contido e afirmava apenas : "perdi, perdi".

Acrescentaram, por fim, que no local havia movimento apenas de pedestres que caminhavam pela via.

Assim, deram voz de prisão ao réu e o conduziram ao hospital, tendo em vista as lesões por ele sofridas no momento da queda.

Richard Barbosa de Souza Silva, inquirido em solo policial, narrou que : "...estava pelo local apenas para comprar 'maconha', porém, antes de adquirir a referida droga, foi abordado pelos policiais civis; QUE, visualizou o momento em que o increpado estava sobre um muro manuseando uma sacola e após o mesmo visualizar os policiais civis, pulou o muro para se evadir e acabou se lesionando." (pág. 09).

No contraditório, entretanto, apresentou esclarecimentos confusos e contraditórios.

Em um primeiro momento, narrou que é morador da comunidade.

Após, declarou que no dia dos fatos estava no local para adquirir droga para seu consumo, "...eu ia pegar também, pro meu uso...".

Questionado pela representante do Ministério Público, confirmou que Fernando iria lhe entregar a droga.

Disse que "...a sacola estava na viela onde fica o traficante...", e não soube dizer se pertencia ao acusado.

Após, afirmou que não viu o réu com a sacola apreendida e que não chegou a pedir a droga para Fernando.

Declarou, ainda, que quando chegou no local o acusado já estava detido pelos policiais.

Como consignado, a prova produzida no contraditório bem demonstrou a ocorrência do delito, sendo incontroversa a autoria.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado nada declarou e optou por permanecer em silêncio. Embora direito assegurado pela Constituição Federal, não é postura compatível a situação de pessoa inocente, frente a prisão injusta.

Nesse sentido: "(...) embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável aos réus, por a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em juízo" (Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 11ª Câmara, Ap. nº 1.047.891, Relator Renato Nalini).

Razoável mesmo supor que, estivesse sendo vítima de prisão injusta ou abuso policial, trataria de clamar inocência logo na primeira oportunidade de que dispusesse - até mesmo a fim de viabilizar a verificação, pela polícia investigativa, de eventual álibi -, sobretudo diante de tão grave imputação.

Mas não foi o que fez o réu, que preferiu permanecer em silêncio, pronunciando-se somente em Juízo, meses depois.

No contraditório, entretanto, negou o cometimento do crime, tentou convencer que estava executando um trabalho para um morador da mesma rua, que o contratou para carregar blocos para cima de uma laje. Justificou que trabalhava na feira e era seu dia de folga, sugerindo que executava um trabalho extra para ganhar dinheiro.

Entretanto, o acusado não comprovou nem uma coisa nem outra, ou seja, que estivesse trabalhando na feira, ou que no dia em que foi preso executava uma tarefa para um vizinho, cujos dados de qualificação não informou. Não esclareceu, sequer, o nome desse indivíduo, ou do tal "Bibi", que teria intermediado esse contato. Ademais, os policiais foram categóricos quando narraram que apenas o réu estava em cima dessa laje, sentado e carregando uma sacola.

Logo, essa singela negativa de autoria não é merecedora de nenhuma credibilidade, uma vez que nem de longe foi comprovada pela Defesa, como lhe competia, nos termos do que prevê o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Assim é que o réu tentou fazer crer que é trabalhador e que foi preso injustamente pelos policiais, que lhe atribuíram a responsabilidade por substâncias entorpecentes que localizaram no local.

Todavia, essa versão se mostrou bastante pueril, previsível e inconsistente. Aliás, acatar a falaciosa fala do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos policiais com o exclusivo objetivo de incriminar injustamente pessoa que sequer conheciam.

Não parece mesmo crível.

No caso em apreço, o réu foi surpreendido no período da manhã, em cima de uma laje, e carregando uma mochila contendo inúmeras de maconha e crack. No momento em que percebeu a aproximação dos policiais, na tentativa de empreender fuga, pulou dessa laje e fraturou os pés.

Os policiais ouvidos, de forma bastante serena e insuspeita deram conta da diligência que realizaram e que culminou com a localização de inúmeras porções de drogas em poder do réu.

Vale consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentaram só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas".(TJRJ - AC - Rel Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

O acusado portava drogas fracionadas e diversificadas, em quantidade incompatível com a posse para mero consumo, ou seja, 262 porções de maconha e 400 de crack.

Ademais, as circunstâncias da prisão afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da Lei especial.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76." (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Logo, comprovado o desiderato de mercancia, incontroversa a autoria, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão juntada às págs. 75/76 dá conta de uma condenação definitiva suportada pelo réu, pela prática de crime da mesma natureza, oriunda de processo que tramitou perante a 24ª Vara Criminal da Capital, cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 28/11/2019, que configura reincidência.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu. O artigo 42 da Lei 11.343/06, que prepondera sobre critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, determina que, na fixação das penas, deverão ser consideradas a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em apreço, como dito, o réu foi trazia consigo expressiva quantidade de drogas – que totalizou aproximadamente um quilo e meio (págs. 34/37) – separadas por 263 porções de maconha e 400 porções de crack – entorpecente suficiente para servir inúmeros usuários, o que compromete sobremaneira a saúde pública. Ademais, boa parte era cocaína na forma de crack, substância altamente nociva e viciante, a denotar que se dedica à atividade criminosa em questão, não sendo esse um fato isolado em sua vida, até porque registra condenação anterior por crime da mesma natureza, que praticou exatamente no mesmo local.

Por esses argumentos, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

Por fim, pela reincidência comprovada, agravo a pena em mais 1/6, tornando-a definitiva em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Pelas razões consignadas quando da fixação da pena-base, bem como pela comprovada reincidência específica, não estão presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

E não existe a desproporção no que diz respeito a dosimetria da pena, por conta da reincidência.

Nesse sentido: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- Na hipótese sub exame, configurada a reincidência, posto persistente a tipificação do delito de posse para uso próprio, bem como não existe a necessidade que a condenação definitiva pelo delito anterior seja privativa de liberdade. Precedentes.

- Possível a considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal.

- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas - 26 porções de crack e 1 (um) invólucro plástico de

cocaína, (sabe-se que o crack é uma substância que possui um alto efeito devastador, devendo-se impor um maior rigor na apreciação da conduta do paciente) - , e a reincidência da paciente, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.". (HC 236982 SP 2012/0058827-2 Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE)).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FERNANDO JOSÉ DOS REIS , R.G. nº 35.946.339, e o condeno ao cumprimento de sete anos de reclusão e ao pagamento do valor setecentos dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista a reincidência específica comprovada, bem como o que dispõe a Lei 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, §1º da lei 8.072/90.

Considerando-se que o crime aqui tratado é considerado hediondo, a reincidência específica, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra, e igualmente não preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que mostram-se presentes os fundamentos que justificaram a medida, reforçados pela prova produzida no contraditório, o que se faz necessário também para se assegurar a aplicação da lei penal com o cumprimento da pena aqui aplicada (artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal).

Eventual progressão de regime de cumprimento de pena é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alínea "b", da lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Condeno o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal. Não obstante beneficiário da gratuidade da justiça, o momento oportuno para se decidir pela necessidade de isenção de custas é por ocasião da execução criminal, oportunidade apropriada e que se dará análise mais detalhada a respeito da capacidade financeira do condenado.

Nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal, em se tratando de ação penal pública, se de fato se verificar o estado de pobreza do condenado, o pagamento não será dispensado, mas sim sobrestado, o que deverá ser reavaliado no momento oportuno, pelo Juízo das Execuções Criminais, competente para decidir a respeito.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA